

5. CUESTIONES MATRIMONIALES. EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TESTAMENTO, LEGÍTIMAS Y SUCESIÓN INTESADA. PARTICIÓN DE LA HERENCIA

5.1. Cuestiones matrimoniales

1570

Celebración del matrimonio

Nuestro ordenamiento jurídico contempla y regula de forma expresa a través de las distintas disposiciones del Código Civil como regímenes económicos matrimoniales los siguientes:

- La **sociedad de gananciales** (artículos 1344 a 1410 del CC).
- El **régimen de participación en las ganancias** (artículos 1411 a 1434 del CC).
- El **régimen de separación de bienes** (artículos 1345 a 1444 del CC).

El régimen económico matrimonial será aquel que los cónyuges decidan libremente a través de las capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en el CC. Sin embargo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1316 del Código Civil, a falta de pacto, o en aquellos supuestos en los que las capitulaciones matrimoniales resultaran ineficaces, el régimen económico matrimonial aplicable es el de sociedad de gananciales.

A TENER EN CUENTA. Lo dispuesto en el artículo 1315 del CC fue objeto de examen en la primera convocatoria del año 2022.

De acuerdo con el artículo 1325 del CC, los otorgantes de capitulaciones matrimoniales podrán estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del matrimonio.

Las capitulaciones matrimoniales **podrán otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio, si bien cuando las mismas se otorguen antes del matrimonio este debe de celebrarse en el plazo de un año** (arts. 1326 y 1334 del CC).

Para que las capitulaciones sean válidas, deberán otorgarse en escritura pública (art. 1327 del CC).

Será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge (art. 1328 del CC).

El menor no emancipado que con arreglo a la ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero **necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación** (art. 1329 del CC).

Para que sea válida la modificación de las capitulaciones matrimoniales, deberá realizarse con la asistencia y concurso de las personas que en estas intervinieron como otorgantes si vivieren y la modificación afectare a derechos concedidos por tales personas (art. 1331 del CC).

CUESTIONES

1. Manuel y Vanesa van a contraer matrimonio y quieren establecer el régimen de separación de bienes, pero no tienen claro cómo han de proceder. Indique la respuesta correcta.

- a) Manuel y Vanesa podrán otorgar capitulaciones matrimoniales antes o después de celebrar el matrimonio.
- b) Manuel y Vanesa antes de otorgar capitulaciones deberán contraer matrimonio.
- c) Manuel y Vanesa podrán otorgar capitulaciones matrimoniales antes de contraer matrimonio, pero el régimen de separación de bienes solo podrán establecerlo una vez celebrado el matrimonio.
- d) Manuel y Vanesa deberán otorgar capitulaciones antes de celebrar el matrimonio en todo caso.

RESPUESTA CORRECTA: A

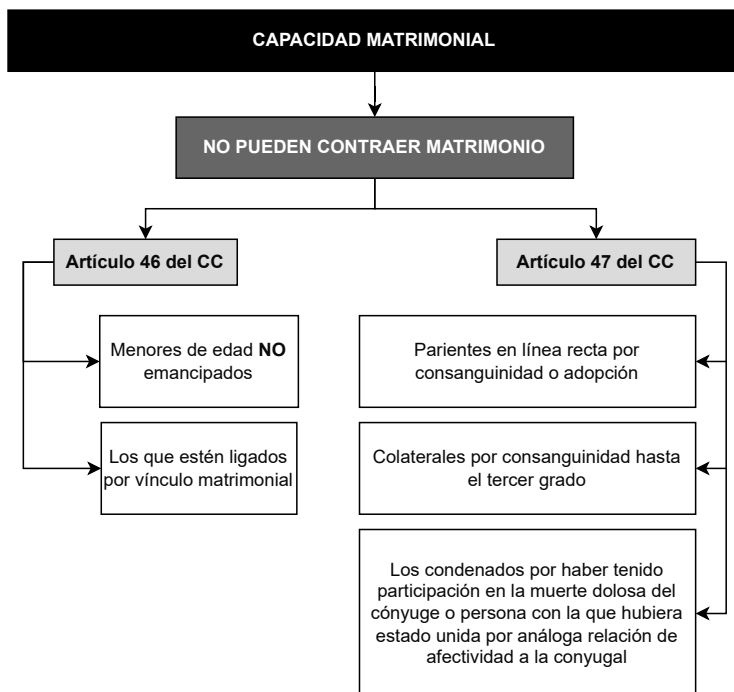
2. Pablo y Miguel contrajeron matrimonio el 10 de septiembre de 2016, con arreglo al Código Civil, en Luarca, ciudad donde residen y tienen su vivienda habitual. La intención de Pablo y Miguel —siendo solteros— era la de contraer matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, por lo que, el 10 de abril de 2014, otorgaron capitulaciones matrimoniales acordando el régimen de separación de bienes ante un notario de Gijón. Señala la respuesta correcta:

- a) El régimen económico de su matrimonio será el de separación de bienes de acuerdo con las capitulaciones.
- b) El régimen económico de su matrimonio será el de la sociedad de gananciales, pues en el momento de contraer matrimonio lo estipulado en sus capitulaciones había quedado sin efecto.
- c) El régimen económico de su matrimonio será el gananciales, pues para que las capitulaciones de modificación del régimen económico matrimonial surtan efectos habrá que otorgarlas con posterioridad a la celebración del matrimonio.
- d) El régimen económico de su matrimonio será el de la sociedad de gananciales, pues las capitulaciones deberían haberse otorgado ante un/una notario en Ponferrada.

RESPUESTA CORRECTA: B

En cuanto a los **requisitos** necesarios para la celebración del matrimonio, cabe mencionar:

- **Capacidad matrimonial.** Para poder contraer matrimonio, los contrayentes han de tener una mínima capacidad y aptitud personal. Dichos requisitos de capacidad se encuentran regulados en los artículos 44, 46, 47 y 48 del Código Civil. En cuanto a los posibles **impedimentos básicos para la celebración del matrimonio**, cabe destacar el **impedimento de edad**, **impedimento de vínculo**, **impedimento de parentesco** y el **impedimento de crimen**.



CUESTIÓN

Lara cumplirá 15 años en menos de un mes y desea contraer matrimonio dentro de tres meses con su novio de 20 años. Indica la opción correcta:

- Lara puede contraer matrimonio si sus padres lo autorizan ante el encargado/a del Registro Civil.
- Lara puede contraer matrimonio ya que cuando contraiga matrimonio tendrá 15 años y la edad mínima para hacerlo es de 14 años.
- Lara no puede contraer matrimonio en este momento.
- Lara podrá contraer matrimonio si obtiene una dispensa judicial, que deberá solicitar ante el juez de primera instancia.

RESPUESTA CORRECTA: C

- **Consentimiento matrimonial.** Señala el artículo 45 del Código Civil que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.
- **Forma.** En este sentido, para lograr la validez del matrimonio, se requiere que el consentimiento se preste en alguna de las formas contempladas en el Código Civil. Del mismo modo, se concede la posibilidad a las partes de exteriorizar la celebración del mismo tanto por ritos religiosos como por la ceremonia civil. Por otro lado, conviene considerar supuestos especiales, pues ante la concurrencia de causa grave suficientemente justificada, se prevé la posibilidad de la celebración del matrimonio civil en secreto (art. 54 del Código Civil); de igual modo, existe la posibilidad de celebración de matrimonio en peligro de muerte (art. 52 del Código Civil).

A TENER EN CUENTA. El art. 52 del CC ha sido modificado por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, con entrada en vigor el 3 de abril de 2025, eliminando la competencia del juez de paz para celebrar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte.

Igualmente, es preciso aludir a los **derechos y deberes generados para ambos cónyuges tras la celebración del matrimonio**, siendo necesario para ello acudir a lo establecido en los artículos 67 a 71 del Código Civil. En atención a los mismos, se puede decir que los cónyuges tienen:

- a) El deber de respetarse y ayudarse mutuamente.
- b) El deber de actuar en interés de la familia.
- c) El deber de guardarse fidelidad.
- d) El deber de vivir juntos (a este respecto existe presunción de convivencia) y de fijar un domicilio común, advirtiéndose de que, en el caso de que no lleguen a un acuerdo, resolverá el juez teniendo en cuenta el interés de la familia.
- e) El deber de socorrerse mutuamente.
- f) El deber de compartir responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y de otras personas dependientes a su cargo.

Lo anterior **debe ser complementado con la obligación recíproca de alimentos contenida en los artículos 142 y 143 del Código Civil.**

Respecto de los **efectos civiles** del matrimonio, estos se producirán **desde su celebración, bastando para que los mismos sean reconocidos con la inscripción del matrimonio (art. 61 del CC).**

CUESTIÓN

Laura y Pablo celebraron su matrimonio en el Ayuntamiento de Sevilla el 3 de junio de 2022, si bien, el mismo no fue inscrito en el registro civil hasta el 19 de julio de 2022. ¿Desde cuándo producirá efectos el matrimonio contraído entre Laura y Pablo?

- a) Desde el 3 de junio de 2022.
- b) Desde el 19 de julio de 2022.
- c) Laura y Pablo podrán estipular en los actos preparatorios del matrimonio si su matrimonio produce efectos civiles desde su celebración o, por el contrario, desde su inscripción en el Registro Civil.
- d) Desde que el matrimonio es inscrito en el Ayuntamiento de Sevilla.

RESPUESTA CORRECTA: A

Finalmente, también conviene hacer una sucinta referencia a las denominadas parejas de hecho, entendidas como uniones estables de dos personas del mismo o de distinto sexo en una relación de afectividad análoga a la del matrimonio. Dichas uniones temporales no tienen una regulación propia en nuestro derecho estatal, aunque sí existe una ingente normativa autonómica sobre ello, la cual se ha ocupado en gran medida de la definición y requisitos para apreciar su estabilidad y consiguiente atribución de efectos.

Los procedimientos de nulidad, separación y divorcio

El **divorcio** supone la disolución del vínculo matrimonial y la posibilidad de volver a contraer matrimonio en el orden civil. Implica la extinción del régimen de los derechos y obligaciones que se generan en el momento del matrimonio, a excepción (por cuanto en nuestro ordenamiento no existe diferencia alguna entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales) de las relativas a los hijos de ambos cónyuges.

Por Ley 15/2005, de 8 de julio, se procedió a modificar el Código Civil y la LEC, eliminándose como requisitos para el divorcio el cumplimiento de las causas legales existentes hasta el momento y se permitió que se **pudiese solicitar el divorcio a los tres meses de la celebración del matrimonio sin necesidad de separarse previamente ni de alegar causa alguna**. (De ahí la denominación popular de «divorcio exprés»).

Pueden diferenciarse dos formas de inicio en el proceso de divorcio, en atención al grado de acuerdo existente entre los cónyuges:

- **Divorcio de mutuo acuerdo:** se produce cuando lo solicitan ambos cónyuges o uno con el consentimiento del otro, siendo requisitos necesarios el transcurso de 3 meses desde la celebración del matrimonio y la presentación de un convenio regulador junto con la interposición de la demanda.
- **Divorcio contencioso:** tiene lugar cuando lo solicita un solo cónyuge al no haber acuerdo entre las partes. Es necesario que hayan transcurrido, al menos, 3 meses desde la celebración del matrimonio, y que la parte conyugal que interponga la demanda la acompañe de una petición de las medidas definitivas que han de regular los efectos del divorcio.

En cuanto a la **legitimación**, se considera que ostentan legitimación activa para interponer la acción del divorcio, conforme a lo establecido en el artículo 86 del Código Civil, los dos cónyuges.

No obstante, **se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro**, cuando concurren los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81 del Código Civil.

Existen **dos causas que extinguen la acción del divorcio** (artículo 88 del Código Civil):

- La **muerte de cualquiera de los cónyuges** (o la declaración de fallecimiento) hará que se extinga la acción sea cual fuere la fase procesal en la que se halle el procedimiento.
- La **reconciliación**, que deberá ser expresa cuando se produzca después de interpuesta la demanda. La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales.

CUESTIÓN

Laura interpuso demanda de divorcio frente a Iván el 19 de octubre de 2020. El 21 de octubre de 2020 deciden reconciliarse y darse una nueva oportunidad. El tribunal todavía no ha dictado sentencia en cuanto al divorcio. Laura e Iván acuden al despacho de María para informarse de cómo proceder para que no siga adelante la acción de divorcio. María les indica que:

- a) Deberán volver a contraer matrimonio, ya que la acción de divorcio solo se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges.

- b) La reconciliación entre ambos debe de ser expresa cuando se produzca después de interpuesta la demanda.
- c) Una vez recaiga sentencia en el procedimiento de divorcio, Laura e Iván deberán de poner en conocimiento del tribunal ante el que se interpuso la demanda que se han reconciliado para que se proceda a la extinción de la acción de divorcio.
- d) Laura e Iván no deben hacer nada, ya que al reconciliarse la acción de divorcio se extingue automáticamente.

RESPUESTA CORRECTA: B

La demanda de nulidad, separación o divorcio produce por ministerio de la ley, los efectos siguientes de acuerdo con el artículo 102 del CC *[el contenido del artículo 102 del CC ha sido objeto de examen en la primera convocatoria del año 2022]*:

- Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal.
- Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.
- Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
- Cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el registro civil y, en su caso, en los de la propiedad y mercantil.

A TENER EN CUENTA. ¿Se exige MASC en materia de familia? Del artículo 5.2 de la LO 1/2025, de 2 de enero, se infiere la exigencia de MASC en los procesos especiales del libro IV de la LEC donde se incardinan los procesos de familia. Lo anterior permite concluir que es generalizada la aplicación del requisito de procedibilidad en este tipo de procesos. No obstante, esta regla general presenta las excepciones recogidas en el mismo precepto, es decir, no se exige MASC en los casos siguientes:

- La adopción de las medidas previstas en el artículo 158 del CC.
- La adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad.
- La filiación, paternidad y maternidad.
- El ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, la entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores o la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional.

¿Qué ocurre con los procesos de nulidad matrimonial? ¿Es necesario MASC? La LO 1/2025, de 2 de enero, no contempla los procesos de nulidad matrimonial entre las excepciones al requisito procedibilidad de los MASC, así, han sido varias las opiniones que han sostenido la exigencia de MASC en este tipo de procesos, a título de ejemplo cabe citar los criterios sostenidos por CNLAJ, los jueces de familia de Madrid o el partido judicial de Betanzos.

No obstante, también existen opiniones en sentido contrario, en las que se niega la exigencia de MASC en este tipo de procesos, tal es el caso de los LAJ de Bilbao o de la Junta de jueces de Santiago de Compostela la cual excluye el MASC cuando en el proceso se inste solo la nulidad matrimonial sin ninguna otra medida, es decir, cuando el pronunciamiento que recaiga solo afecte al estado civil de las partes.

¿Qué sucede en el caso de divorcios de mutuo acuerdo? ¿Se exige MASC? ¿El convenio regulador vale como MASC? Los criterios unificadores que se han ido conociendo se muestran conformes con negar la exigencia de MASC como requisito de procedibilidad en los procesos de mutuo acuerdo, así citar la opinión de los LAJ de Bilbao o de los jueces del partido judicial de Betanzos. En relación con estos casos se considera el convenio regulador como una de las expresiones más genuinas de un MASC (ICA Gijón).

CUESTIÓN

Lucía, casada con Carlos, otorgó a este último un poder preventivo que solo surtiría efecto en el caso de que, en el futuro, necesitara apoyo para ejercer su capacidad. Pasados cinco años de matrimonio, la pareja se divorcia. ¿Continúa siendo válido el poder conferido por Lucía tras el divorcio?

- a) Sí, la ruptura de la convivencia no provoca en ningún caso la extinción automática del poder.
- b) Sí, la ruptura de la convivencia no implica la extinción automática, excepto si el poderdante hubiese presentado denuncia por delito castigado con pena privativa de libertad superior a tres años.
- c) No, la finalización de la convivencia extingue automáticamente el poder, salvo que el otorgante hubiera manifestado voluntad contraria o que el cese se deba a su internamiento.
- d) No, el fin de la convivencia produce siempre la extinción automática del poder, sin posibilidad de conservar su validez en ningún supuesto.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ El procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo

En el artículo 777 de la LEC se fija el procedimiento por el cual ambos cónyuges (o uno con el consentimiento del otro) presentan petición de separación o divorcio de mutuo acuerdo.

En cuanto a la **competencia territorial** para los divorcios de mutuo acuerdo nos remitiremos al artículo 769.2 de la LEC: será competente la sección de familia del tribunal de instancia del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes.

A TENER EN CUENTA. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, recoge la transformación de los actuales juzgados en las secciones de los tribunales de instancia que se correspondan con las materias de las que aquellos están conociendo. El art. 86 de la LOPJ recoge las competencias de las secciones de familia, infancia y capacidad de los tribunales de instancia.

En los casos de divorcio de mutuo acuerdo, **los cónyuges podrán valerse de una sola defensa y representación.** No obstante, cuando alguno de los pactos propuestos por los cónyuges no fuera aprobado por el tribunal, el letrado de la Administración de Justicia requerirá a las partes a fin de que en el plazo de cinco días manifiesten si desean continuar con la defensa y representación únicas o si, por el contrario, prefieren litigar cada una con su propia defensa y representación. Asimismo, cuando, a pesar del acuerdo suscrito por las partes y homologado por el tribunal, una de las partes pida la ejecución judicial de dicho acuerdo, el LAJ requerirá a la otra para que nombre abogado y procurador que la defienda y represente (art. 750 de la LEC).

CUESTIONES

1. Rubén y Mónica acuden a los tribunales para divorciarse de mutuo acuerdo, si bien, han decidido valerse de una sola defensa y representación para ambos. ¿Rubén y Mónica actúan correctamente?

- a) Sí, aunque podrán comparecer por sí mismos sin necesidad de abogado y procurador.
- b) Sí, en los procedimientos de separación o divorcio solicitado de común acuerdo por los cónyuges, estos podrán valerse de una sola defensa y representación.
- c) No, cada uno de los solicitantes tendrá que estar asistido de abogado y representado por procurador, sin que puedan valerse de una sola defensa y representación.
- d) No, en los procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo los cónyuges no podrán acudir asistidos de ninguna defensa ni representación.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Lourdes y Javier han decidido, después de una larga crisis matrimonial, divorciarse de mutuo acuerdo, pero no tienen claro cuál es el órgano judicial competente territorialmente donde presentar la solicitud de divorcio. Señala la respuesta correcta:

- a) El del último domicilio común donde han residido Lourdes y Javier o bien el domicilio de Lourdes o de Javier indistintamente.
- b) Solo podrán presentar la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo en el tribunal del último domicilio común de Lourdes y Javier.
- c) Solo en el tribunal del domicilio del solicitante que vaya a presentar la solicitud en los tribunales.
- d) Al ser un divorcio de mutuo acuerdo, podrán presentar la solicitud en cualquier tribunal, independientemente del domicilio de los solicitantes.

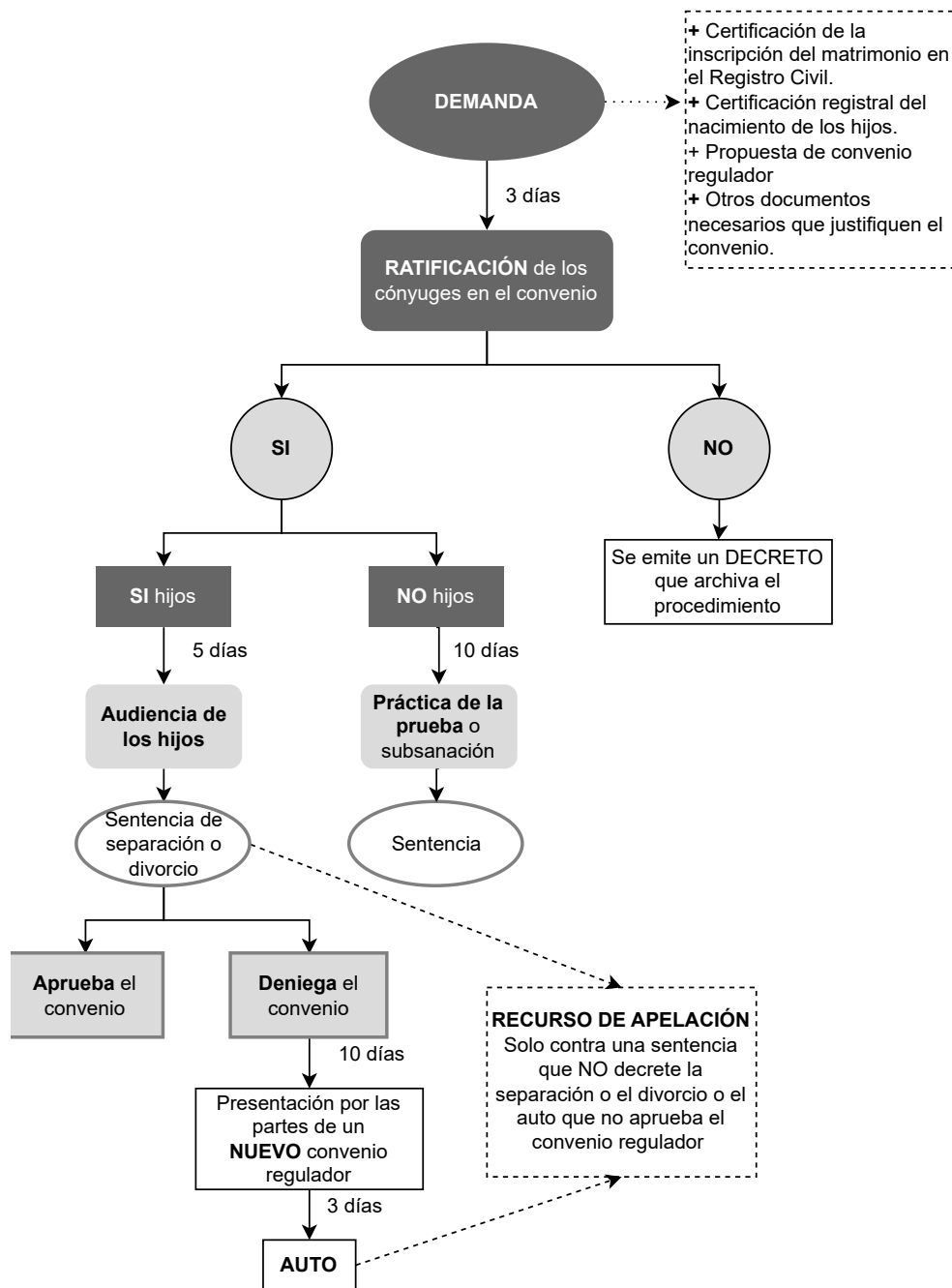
RESPUESTA CORRECTA: A

3. Isabel y Antonio se han divorciado de mutuo acuerdo asistidos ambos con la misma defensa y representación. Pese a que el órgano judicial homologó el acuerdo de divorcio, Isabel está segura de que Antonio no cumple dicho acuerdo e incumple algunas de las medidas acordadas. Isabel solicita la ejecución judicial del acuerdo. Indica la respuesta correcta:

- a) El acuerdo ya ha sido homologado judicialmente, por lo que Isabel no podrá pedir la ejecución del mismo.
- b) El letrado de la Administración de Justicia requerirá a Antonio para que nombre abogado y procurador que lo defienda y represente.
- c) Antonio podrá acudir con la misma defensa y representación que Isabel al tratarse de un divorcio de mutuo acuerdo.
- d) El letrado de la Administración de Justicia requerirá a Isabel y Antonio para que en el plazo de cinco días manifiesten si desean continuar con la defensa y representación únicas o prefieren acudir cada uno con su propia defensa y representación.

RESPUESTA CORRECTA: B

PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO



➤ **Procedimientos contenciosos de nulidad, separación y divorcio**

Los procedimientos contenciosos de nulidad, separación y divorcio, entendidos estos como **procesos matrimoniales civiles especiales**, tienen regulación específica por parte de los artículos 769 y ss. de la LEC.

Las demandas de separación y divorcio, las de nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al amparo del título IV del libro I del Código Civil **se sustanciarán por los trámites del juicio verbal**, de conformidad con lo expuesto en el artículo 770 de la LEC.

El proceso por el que se tramitará una separación, divorcio o nulidad matrimonial en las que no exista acuerdo entre las partes, será el del juicio verbal regulado en los artículos 437 a 447 de la LEC. Si bien, habrá de tenerse en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 748 y siguientes, al resultar estas de aplicación a los procesos de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los procesos de modificación de medidas adoptadas en ellos, y con sujeción, además, a las **reglas contempladas en el artículo 770 de la LEC**.

A TENER EN CUENTA. Los arts. 438, 439, 439.bis, 440, 443, 444, 445 y 447 han sido modificados por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 abril de 2025.

CUESTIÓN

Lucía planteó demanda de separación matrimonial frente a David. ¿Podrá David formular reconvencción?

- a) Sí, pero solo cuando la reconvencción se funde en algunas de las causas que pueden dar lugar a la nulidad del matrimonio.
- b) En todo caso David puede formular reconvencción.
- c) David no puede formular reconvencción, en los procesos matrimoniales no cabe reconvencción en ningún caso.
- d) Sí, cuando David pretenda la nulidad o el divorcio, o que se adopte alguna medida definitiva que no hubiera sido solicitada en la demanda, y sobre la que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.

RESPUESTA CORRECTA: D

En cuanto a las **medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio**, están reguladas en el artículo 771 de la LEC.

CUESTIÓN

Laura y José han decidido divorciarse y Laura solicita, sin intervención de abogado ni procurador, medidas provisionales previas ante el tribunal del domicilio familiar. Señala la respuesta correcta:

- a) Laura debe de presentar las medidas provisionales previas asistida de abogado/a y procurador/a.
- b) El órgano judicial competente para presentar la solicitud de medidas provisionales es el del lugar donde Laura y José contrajeron matrimonio, no el del domicilio familiar.
- c) Para formular la solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior.

- d) Los efectos de las medidas provisionales que se acuerden solo subsistirán si, dentro del plazo de un año desde su adopción, se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio.

RESPUESTA CORRECTA: C

De acuerdo con el artículo 772 de la LEC, **cuando se hubieren adoptado medidas con anterioridad a la demanda**, admitida esta, el letrado de la Administración de Justicia unirá las actuaciones sobre adopción de dichas medidas a los autos del proceso de nulidad, separación o divorcio, solicitándose, a tal efecto, el correspondiente testimonio, si las actuaciones sobre las medidas se hubieran producido en tribunal distinto del que conozca de la demanda.

Solo cuando el tribunal considere que procede completar o modificar las medidas previamente acordadas ordenará que se convoque a las partes a una comparecencia, que señalará el LAJ y se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno.

El cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el divorcio podrá pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisionales a adoptar, siempre que no se hubieren adoptado con anterioridad. También podrán ambos cónyuges someter a la aprobación del tribunal el acuerdo a que hubieren llegado sobre tales cuestiones. Dicho acuerdo no será vinculante para las pretensiones respectivas de las partes ni para la decisión que pueda adoptar el tribunal en lo que respecta a las medidas definitivas.

Admitida la demanda, el tribunal resolverá sobre las peticiones a que se refiere el apartado anterior y, en su defecto, acordará lo que proceda, dando cumplimiento, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 103 del Código Civil.

A TENER EN CUENTA. El artículo 103 del CC fue modificado por la Ley 17/2021, de 15 de diciembre por la que se añade al referido precepto la medida 1.ª bis sobre los animales de compañía, en vigor desde el 5 de enero de 2022.

Antes de dictar el tribunal la resolución a que se refiere el apartado anterior, el LAJ convocará a los cónyuges y, en su caso, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia, que se sustanciará conforme a lo previsto en el artículo 771 de la LEC.

Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno.

También podrá solicitar medidas provisionales el cónyuge demandado, cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por el actor, con arreglo a lo dispuesto en los apartados precedentes. La solicitud deberá hacerse en la contestación a la demanda y se sustanciará en la vista principal, cuando esta se señale dentro de los diez días siguientes a la contestación, resolviendo el tribunal por medio de auto no recurrible cuando la sentencia no pudiera dictarse inmediatamente después de la vista.

Si la vista no pudiera señalarse en el plazo indicado, el letrado de la Administración de Justicia convocará la comparecencia que se sustanciará según lo previsto en el artículo 771 de la LEC.

Las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo.

Los artículos 774 y 775 de la LEC se refieren a las **medidas definitivas**.

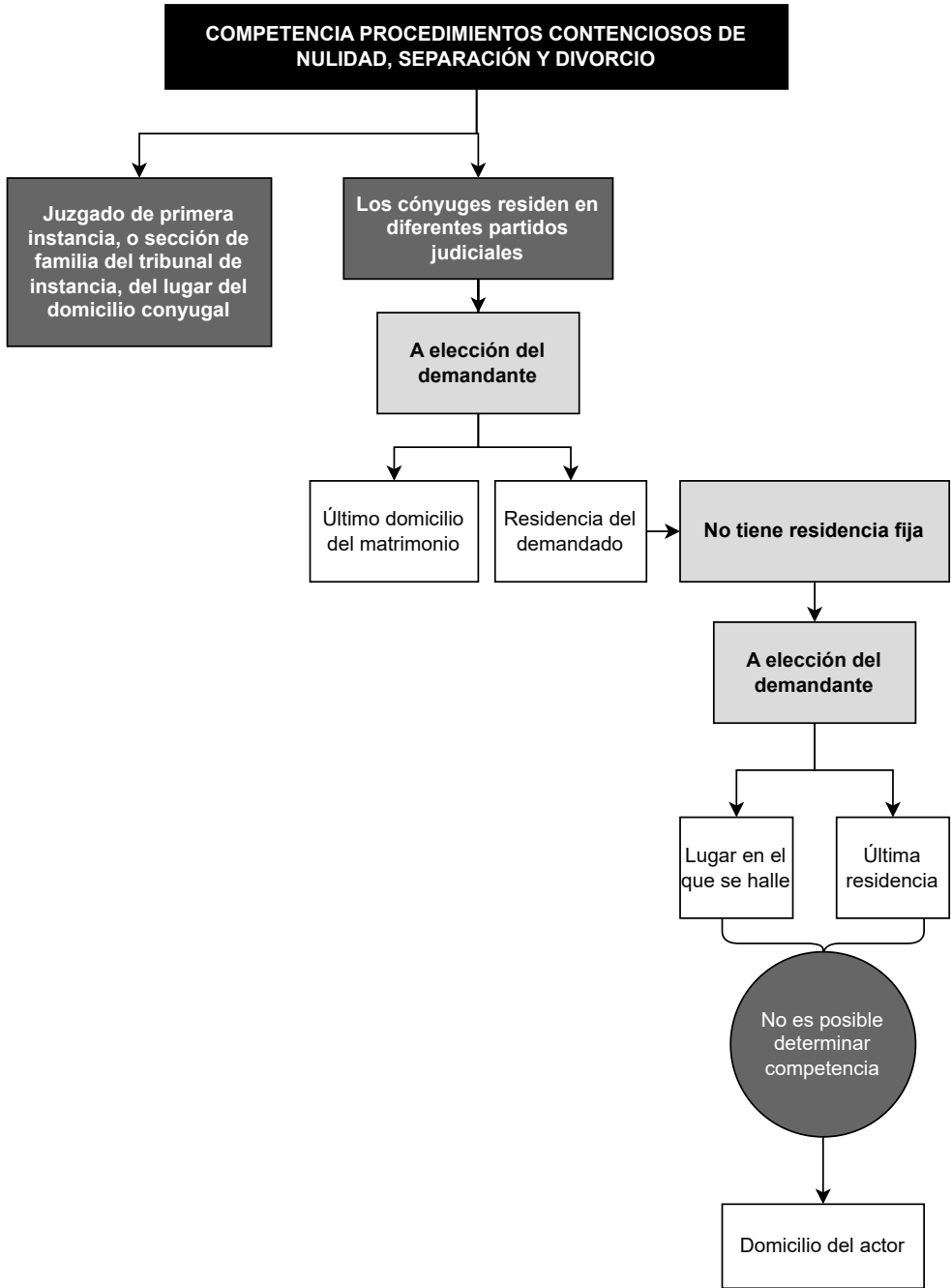
A TENER EN CUENTA. El apdo. 4 del artículo 774 de la LEC ha sido modificado por la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, añadiendo la atribución, convivencia y necesidades de los animales, en vigor desde el 5 de enero de 2022.

Como nos relata el comienzo del artículo 776 de la LEC, los pronunciamientos sobre medidas adoptadas en los procesos matrimoniales se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el libro III de la LEC, y se sujetarán a las siguientes especialidades:

1. **Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el letrado de la Administración de Justicia multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 711 de la LEC y sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas.**
2. **En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario prevista en el apartado tercero del artículo 709 de la LEC y podrán, si así lo juzga conveniente el tribunal, mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en dicho precepto.**
3. **El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el tribunal del régimen de guarda y visitas siempre y cuando sea acorde con la evaluación del interés superior del menor realizada previamente.** (Modificado el artículo 776 de la LEC, especialidad 3.ª por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024).
4. **Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario.** Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los arts. 440 y siguientes de la LEC, y resolverá mediante auto.

Con respecto a la **competencia**, salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procesos matrimonial la **sección de familia del tribunal de instancia del lugar del domicilio conyugal**. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.

Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante, y si tampoco pudiere determinarse así la competencia, corresponderá esta al tribunal del domicilio del actor (art. 769.1 de la LEC).



CUESTIÓN

Alejandra quiere presentar demanda de divorcio frente a su esposo Roberto. Alejandra y Roberto tenían su domicilio habitual en A Coruña. Cuando tomaron la decisión de separarse en el año 2018, Roberto se fue a vivir a Madrid y Alejandra a Valencia. En este caso, ¿qué tribunal será el competente para conocer de la acción de divorcio?

- a) El Tribunal de Instancia de Valencia por ser el domicilio de Alejandra, que es la parte demandante.
- b) El Tribunal de Instancia de A Coruña por ser el domicilio habitual del matrimonio.
- c) El Tribunal de Instancia de A Coruña o el de Madrid, a elección de Alejandra como parte demandante.
- d) El Tribunal de Instancia de A Coruña o el de Madrid, a elección de Roberto por ser la parte demandada.

RESPUESTA CORRECTA: C

5.2. Edad y personas con discapacidad

Minoría de edad

1590

➤ De la mayor edad y de la emancipación

De acuerdo con el artículo 240 del CC, **la mayor edad empieza a los 18 años cumplidos**. En cuanto al cómputo de los años de la mayoría de edad, el referido artículo dispone que **el día del nacimiento se incluirá entero**.

A TENER EN CUENTA. Lo contemplado en el segundo párrafo del artículo 240 del CC fue objeto de examen en la primera convocatoria del año 2022.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 246 del CC, el mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo excepciones establecidas en casos especiales por el Código Civil.

En el referido artículo se contempla el principio de presunción general de capacidad, que ya resulta de nuestro ordenamiento jurídico y ha quedado reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

En atención al **artículo 245 del CC**:

«También podrá la autoridad judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare».

De acuerdo con el **artículo 239 del CC**, la emancipación tiene lugar:

1. Por la **mayor edad**.
2. Por **concesión de los que ejerzan la patria potestad**.
3. Por **concesión judicial**.

Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y que, además, la consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil (artículo 241 del CC).

La referida concesión de la emancipación **habrá de inscribirse en el registro civil**, no produciendo, entre tanto, efectos contra terceros.

Concedida la emancipación, no podrá ser revocada, tal y como dispone el artículo 242 del CC.

La autoridad judicial podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si estos la pidieren y previa audiencia de los progenitores cuando:

1. Quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor.
2. Los progenitores vivieren separados.
3. Concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad.

Según lo dispuesto en el **artículo 247 del CC**, la emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor.

Sin embargo, el emancipado no podrá, hasta que alcance la mayoría de edad:

1. Tomar dinero a préstamo.
2. Gravar o **enajenar** bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus progenitores y, a falta de ambos, sin el defensor judicial.

El emancipado podrá comparecer en juicio por sí solo. Todo esto también resulta aplicable al menor que hubiera obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad.

Por último, de acuerdo con el artículo 248 del CC, para que el casado menor de edad pueda enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes basta, si es mayor de edad el otro cónyuge, el consentimiento de los dos; si también es menor, se necesitará, además, el de los progenitores o defensor judicial de uno u otro.

➤ **Los procesos de menores en la LEC**

Al igual que sucede con todos los procesos relacionados en el artículo 748 de la LEC, los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos (reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores) habrán de tener presentes las siguientes especialidades:

- En ellos **es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal** (artículo 749 de la LEC).
- Las partes **actuarán con asistencia de abogado y representadas por procurador**, salvo en aquellos casos en que la misma sea defendida por el Ministerio Fiscal (artículo 750 de la LEC).
- El **objeto del proceso es indisponible**, esto es, en los mismos no cabe la renuncia, el allanamiento ni la transacción y el desistimiento, por regla general, requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal (artículo 751 de la LEC).

La **tramitación** de estos procedimientos será **preferente y, salvo disposición expresa**, se sustanciará por los **trámites del juicio verbal** con las siguientes especialidades que indica el artículo 753 de la LEC:

A TENER EN CUENTA. El artículo 753 de la LEC se ha visto modificado por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024.

- El letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el artículo 405 de la LEC.
- Cuando se presente ante un tribunal civil una demanda relativa a los procesos a que se refiere este título, de la que pueda ser competente por razón de la materia la sección **de violencia sobre la mujer** conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se recabará la oportuna consulta al sistema de **registros administrativos** de apoyo a la Administración de Justicia, así como al sistema de gestión procesal correspondiente a fin de verificar la competencia conforme al artículo 49 bis de esta ley.

La consulta al sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y al sistema de gestión procesal correspondiente se reiterará antes de la celebración de la vista o comparecencia del procedimiento contencioso o de jurisdicción voluntaria o del acto de ratificación de los procedimientos de mutuo acuerdo.

Del mismo modo, en el decreto de admisión, se requerirá a las partes para que comuniquen, en el plazo de cinco días, si existen o han existido procedimientos de violencia sobre la mujer entre los cónyuges o progenitores, su estado procesal actual, y si constan adoptadas medidas civiles o penales. Igualmente se advertirá a ambas partes de la obligación de comunicar inmediatamente cualquier procedimiento que inicien ante la sección de violencia sobre la mujer durante la tramitación del procedimiento civil, así como cualquier incidente de violencia sobre la mujer que se produzca.

A TENER EN CUENTA. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, recoge la transformación de los actuales juzgados en las secciones de los tribunales de instancia que se correspondan con las materias de las que aquellos están conociendo. Si bien la entrada en vigor se ha producido el 23 de enero de 2025, la D.T. 1ª de la mentada ley establece distintos plazos para la transformación que van desde el 1 de julio de 2025, al 31 de diciembre de 2025.

- En la celebración de la vista de juicio verbal en estos procesos y de la comparecencia a que se refiere el artículo 771 de la presente ley, una vez practicadas las pruebas, el tribunal permitirá a las partes formular oralmente sus conclusiones, siendo de aplicación a tal fin lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 433 del mismo texto legal.
- Los procesos a los que se refiere este título serán de tramitación preferente siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, persona con discapacidad con medidas judiciales de apoyo en las que se designe un apoyo con funciones representativas, o esté en situación de ausencia legal.

Por lo que respecta a la competencia, el apartado 3 del artículo 769 LEC determina que **es competente territorialmente la sección de familia, infancia y capacidad del tribunal de instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores, y si residen en distintos partidos, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de residencia del menor.**

A TENER EN CUENTA. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, recoge la transformación de los actuales juzgados en las secciones de los tribunales de instancia que se correspondan con las materias de las que aquellos están conociendo. Si bien la entrada en vigor se ha producido el 23 de enero de 2025, la D.T. 1ª de la mentada ley establece distintos plazos para la transformación que van desde el 1 de julio de 2025, al 31 de diciembre de 2025. Las competencias de las secciones de familia, infancia y capacidad se prevén el art. 86 de la LOPJ.

Por otro lado, el apartado 6 del artículo 770 de la LEC que para la **adopción de las medidas cautelares** que sean adecuadas a estos procesos se seguirán los trámites establecidos en la ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio.

En estos casos de pretensiones exclusivas, para la adopción de medidas cautelares que sean idóneas para la tutela deseada a través de dichos procesos, se seguirán los trámites establecidos para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio.

CUESTIÓN

Roberto ha presentado una demanda de impugnación de la filiación de su hijo Alejandro, menor de edad. Señala la respuesta correcta:

- a) El Ministerio Fiscal nunca es parte en los procedimientos sobre impugnación de la filiación.
- b) En el caso de que Roberto actúe con asistencia de abogado y representado por procurador, no será necesaria la intervención del Ministerio Fiscal.
- c) En los procesos de impugnación de la filiación será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor del proceso.
- d) El Ministerio Fiscal será parte en el procedimiento de impugnación de la filiación siempre que haya sido promotor del proceso y deba asumir la defensa de alguna de las partes.

RESPUESTA CORRECTA: C

1600

Adopción de medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica

➤ **Finalidad y medidas**

De acuerdo con el **artículo 249 del Código Civil**, la **finalidad** de las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipados que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica será la de **permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad**.

Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el **respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales**.

Por otro lado, las medidas de apoyo que tengan origen legal o judicial únicamente procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate.

En lo que respecta a las personas que presten apoyo, **deberán actuar siempre de acuerdo con la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera**. Además, procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que

pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro.

De manera excepcional, **cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de las personas, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas.** En este caso, en el ejercicio de esas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación.

Finalmente, **la autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios establecidos en el precitado artículo 249 del Código Civil y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y preferencias que las requiera.**

¿Cuáles son las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica? De acuerdo con el artículo 250 del CC:

- **Medidas de apoyo de naturaleza voluntaria:** son las establecidas por la persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.
- **Guarda de hecho:** medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.
- **Curatela:** medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo.
- **Defensor judicial:** medida formal de apoyo que procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente.

Cuando se determine alguna de las citadas medidas de apoyo habrá que **evitar siempre situaciones en las que se puedan producir situaciones de conflicto de intereses o influencia indebida.**

Asimismo, **no podrán ejercer ninguna de las mencionadas medidas de apoyo quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo.**

¿Su función? Asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias.

➤ **Procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad (artículos 756 a 763 de la LEC)**

◆ **Ámbito de aplicación y competencia (artículo 756 de la LEC)**

En los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación civil aplicable, sea pertinente el nombramiento de curador y en el expediente de jurisdicción voluntaria dirigido a tal efecto se haya formulado oposición, o cuando el expediente no haya podido resolverse, la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad se registrará por lo establecido en el capítulo II, título I, libro IV de la LEC.

Será competente para conocer de las demandas sobre la adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad la autoridad judicial que conoció del previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será la sección de familia, infancia y capacidad del tribunal de instancia del lugar en que esta resida.

Si antes de la celebración de la vista se produjera un cambio de la residencia habitual de la persona a que se refiera el proceso, se remitirán las actuaciones a la sección del tribunal correspondiente en el estado en que se hallen.

A TENER EN CUENTA. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, recoge la transformación de los actuales juzgados en las secciones de los tribunales de instancia que se correspondan con las materias de las que aquellos están conociendo. Si bien la entrada en vigor se ha producido el 23 de enero de 2025, la D.T. 1ª de la mentada ley establece distintos plazos para la transformación que van desde el 1 de julio de 2025, al 31 de diciembre de 2025. Las competencias de las secciones de familia, infancia y capacidad se prevén el art. 86 de la LOPJ.

♦ Legitimación e intervención procesal (artículo 757 de la LEC)

El proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona con discapacidad puede promoverlo:

- La propia persona interesada.
- Su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
- Su descendiente, ascendiente o hermano.

El **Ministerio Fiscal** deberá promover dicho proceso si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no hubieran presentado la correspondiente demanda, salvo que concluyera que existen otras vías a través de las que la persona interesada pueda obtener los apoyos que precisa.

CUESTIÓN

Tania, abogada en ejercicio, está redactando una demanda para iniciar in procedimiento judicial de adopción de medidas de apoyo a favor de una persona con discapacidad. ¿Quiénes tienen legitimación para promover dicho procedimiento?

- a) Están legitimados su cónyuge no separado de hecho ni legalmente, o quien mantenga con una relación de hecho análoga, el Ministerio Fiscal, sus ascendientes, descendientes, hermanos... pero no la persona interesada.
- b) Están legitimados su cónyuge no separado de hecho ni legalmente, así como sus descendientes, ascendientes o hermanos y el Ministerio Fiscal.
- c) Están legitimados la persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente, o quien se halle en una situación de hecho análoga, sus descendientes, ascendientes o hermanos y el Ministerio Fiscal.
- d) Están legitimados la persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente, o quien mantenga una relación de hecho equiparable, sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado y el Ministerio Fiscal.

RESPUESTA CORRECTA: C

Cuando con la demanda se solicite el inicio del procedimiento de provisión de apoyos, las medidas de apoyo correspondientes y un curador determinado, se le dará a este traslado de aquella a fin de que pueda alegar lo que considere conveniente sobre dicha cuestión.

Las personas legitimadas para instar el proceso de adopción de medidas judiciales de apoyo o que acrediten un interés legítimo podrán intervenir a su costa en el ya iniciado, con los efectos previstos en el artículo 13 de la LEC.

♦ Certificación registral y personación del demandado (artículo 758 de la LEC)

Admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia recabará certificación del registro civil y, en su caso, de otros registros públicos que considere pertinentes sobre las medidas de apoyo inscritas.

Una vez notificada la demanda por medio de remisión o entrega, o por edictos cuando la persona interesada no hubiera podido ser notificada personalmente, si **transcurrido el plazo previsto para la contestación a la demanda, la persona interesada no compareciera ante el tribunal con su propia defensa y representación, el letrado de la Administración de Justicia procederá a designarle un defensor judicial**, a no ser que ya estuviera nombrado o su defensa corresponda al Ministerio Fiscal por no ser el promotor del procedimiento. A continuación, se le dará al defensor judicial un nuevo plazo de veinte días para que conteste a la demanda si lo considera procedente.

Asimismo, el LAJ llevará a cabo las actuaciones necesarias para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la finalidad y los trámites del procedimiento.

CUESTIÓN

El Ministerio Fiscal presenta demanda de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad para Loreto. Señala la respuesta correcta:

- a) Si transcurre el plazo previsto para la contestación a la demanda y Loreto no comparece ante el tribunal con su propia defensa y representación, el letrado de la Administración de Justicia procederá a designarle un defensor judicial.
- b) A Loreto la defenderá el Ministerio Fiscal en todo caso.
- c) Loreto únicamente podrá comparecer representada por un defensor judicial que nombrará el letrado de la Administración de Justicia.
- d) Loreto al ser una persona con discapacidad y no comprender el objeto, la finalidad y los trámites del procedimiento, le representará el familiar más cercano.

RESPUESTA CORRECTA: A

♦ Pruebas preceptivas en primera y segunda instancia (art. 759 de la LEC)

En los procesos sobre adopción de medidas de apoyo a las que se refiere el capítulo II, título I, libro IV de la LEC, además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 752 de la LEC, el tribunal practicará las siguientes:

1. Se entrevistará con la persona con discapacidad.
2. Dará audiencia al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se encuentre en situación de hecho asimilable, así como a los parientes más próximos de la persona con discapacidad.

3. Acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que deben adoptarse sin previo dictamen pericial acordado por el tribunal. Para dicho dictamen preceptivo se contará en todo caso con profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, y podrá contarse también con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso.

Si bien, en los casos en que la demanda haya sido presentada por la propia persona con discapacidad, el tribunal podrá, previa solicitud de esta y de forma excepcional, no practicar las audiencias preceptivas si así resultara más conveniente para la preservación de su intimidad.

Asimismo, cuando el nombramiento de curador no estuviera propuesto, sobre esta cuestión se oír a:

1. La persona con discapacidad.
2. El cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se encuentre en situación de hecho asimilable.
3. Sus parientes más próximos.
4. Demás personas que el tribunal considere oportuno, siendo también de aplicación lo dispuesto con anterioridad.

Si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere apelada, se ordenará también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren los apartados anteriores del presente artículo.

♦ Sentencia (art. 760 de la LEC)

Las medidas que adopte la autoridad judicial en la sentencia deberán ser conformes a lo dispuesto sobre esta cuestión en las normas de derecho civil que resulten aplicables.

♦ Revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas (art. 761 de la LEC)

Las medidas contenidas en la sentencia dictada serán revisadas de conformidad con lo previsto en la legislación civil, **debiendo seguirse los trámites previstos a tal efecto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.**

Y, en caso de que se produjera oposición en el expediente de jurisdicción voluntaria de revisión a que se refiere el párrafo anterior, o si dicho expediente no hubiera podido resolverse, se deberá instar el correspondiente proceso contencioso conforme a lo previsto en el capítulo II, título I, libro IV de la LEC, pudiendo promoverlo cualquiera de las personas mencionadas en el apartado 1 del artículo 757 del mismo texto legal, así como quien ejerza el apoyo de la persona con discapacidad.

A TENER EN CUENTA. Este apartado ha sido objeto de pregunta en la prueba de acceso a la abogacía para el año 2021.

♦ Medidas cautelares (art. 762 de la LEC)

Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una persona en una situación de discapacidad que requiera medidas de apoyo, adoptará de oficio las que estime necesarias para la adecuada protección de aquella o de su patrimonio y pondrá el

hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, si lo estima procedente, un expediente de jurisdicción voluntaria.

El Ministerio Fiscal podrá también, en las mismas circunstancias, solicitar del tribunal la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior.

Tales medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del procedimiento.

Siempre que la urgencia de la situación no lo impida, las medidas a que se refieren los apartados anteriores se acordarán previa audiencia de las personas con discapacidad; para ello, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 734, 735 y 736 de la LEC.

♦ Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico (art. 763 de la LEC)

El artículo 763 de la LEC regula el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.

A TENER EN CUENTA. El art. 763 de la LEC tiene carácter orgánico conferido por la disposición adicional 1, en la redacción dada por el art. 2.3 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, en cumplimiento de la **sentencia del TC n.º 132/2010, de 2 de diciembre, ECLI:ES:TC:2010:132**, en la que se declaraba la inconstitucionalidad de determinados incisos.

CUESTIÓN

Nieves está ingresada en una residencia de ancianos ya que hace tres años sufrió un ictus. A causa del ictus, Nieves sufre un deterioro cognitivo grave, no puede hablar ni caminar. Por ello, su hija inicia un proceso judicial para acordar medidas de apoyo con funciones representativas. Indica la respuesta correcta:

- a) El tribunal no puede decidirse sobre las medidas que deben adoptarse sin previo dictamen pericial de profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario. Además, podrá contarse con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso.
- b) Como en este caso no se puede entrevistar a Nieves, el tribunal adoptará las medidas de apoyo tras escuchar a su hija y a un/una representante de la residencia de ancianos.
- c) Ante la urgencia de la situación el tribunal podrá establecer las medidas de apoyo que estime convenientes de manera inmediata.
- d) Al estar Nieves ingresada en una residencia de ancianos y tener todas sus necesidades cubiertas, en este caso no resulta procedente establecer medidas de apoyo.

RESPUESTA CORRECTA: A

5.3. Testamento, legítimas y sucesión intestada

Testamento

1610

El testamento, tal y como apunta el artículo 667 del Código Civil, es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos.

Se trata de un **acto personalísimo**, no podrá dejarse su formación, en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisario o mandatario (excepción hecha de la *fiducia sucesoria* u ordenación de la sucesión por comisario en territorios con de-

recho civil especial o foral), como tampoco dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia del nombramiento de herederos o legatarios, ni la designación de porciones en que hayan de suceder cuando sean instituidos nominalmente (art. 670 del Código Civil).

En derecho común se prohíbe testar a dos o más personas mancomunadamente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan en provecho recíproco o en beneficio de un tercero. Dicha posibilidad, sin embargo, sí se admite en determinados territorios con derecho civil especial o foral como Galicia, País Vasco, Navarra y Aragón.

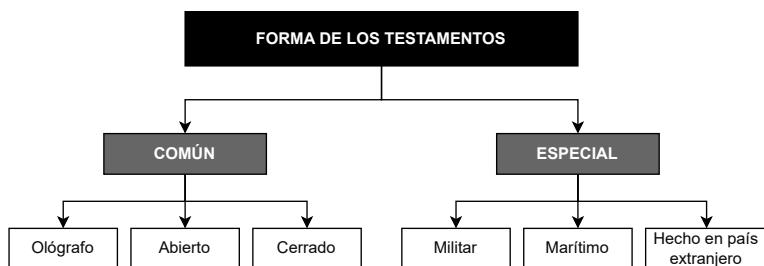
El testamento se caracteriza por ser un acto:

- **Mortis causa:** para que se despliegan los efectos contenidos en el testamento, es necesario esperar a la declaración de fallecimiento del testador.
- **Unipersonal:** cada acto testamentario se produce mediante la intervención de un solo testador, no pudiendo estar dos o más personas de forma mancomunada o en un mismo documento testamentario, salvo lo dispuesto para los testamentos mancomunados o de hermandad en Galicia, País Vasco, Navarra y Aragón.
- **Unilateral:** la validez de la declaración de voluntad no requiere para su eficacia que sea recibida o aceptada por ninguna otra parte.
- **Personalísimo:** no puede dejarse su formación ni en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisario o mandatario, excepción hecha de los supuestos de fiducia sucesoria u ordenación de la sucesión por comisario en los territorios con derecho civil especial o foral.
- **Solemne:** es preciso que la voluntad sucesoria recogida en el testamento sea manifestada con las solemnidades establecidas en el Código Civil para alguna de las formas de testar.
- **Revocable:** todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese su voluntad o resolución de no revocarlas.
- **No receptivo:** el testamento, al tratarse de un negocio unilateral, no está orientado a suscitar la confianza en un posible destinatario.

Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. **En caso de duda, se observará lo que aparece más conforme a la intención del testador según el tenor del mismo testamento.**

El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley (art. 675 del CC).

Tipos de testamentos



➤ Testamento ológrafo

El testamento ológrafo (es decir, el realizado de puño y letra del testador) está regulado los artículos 688-693 del CC.

El artículo 688 del Código Civil contiene una serie de reglas o normas relativas al testamento ológrafo:

- Solo podrá otorgarse por personas mayores de edad.
- Tiene que estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue.
- Si contuviese palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma.
- Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma.

El testamento ológrafo deberá protocolizarse, presentándolo, en los cinco años siguientes al fallecimiento del testador, ante notario. Este extenderá el acta de protocolización de conformidad con la legislación notarial, tal y como dispone el artículo 689 del Código Civil.

El artículo 690 del Código Civil señala la **obligación** que tiene la **persona en cuyo poder esté un testamento ológrafo, de presentarlo ante notario competente en los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador.** El incumplimiento de este deber le hará responsable de los daños y perjuicios que haya causado.

También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el testamento como heredero, legatario, albacea o en cualquier otro concepto.

Presentado el testamento ológrafo y acreditado el fallecimiento del testador, se procederá a su adveración conforme a la legislación notarial. Una vez adverado el testamento y acreditada la identidad de su autor, se procederá a su protocolización (arts. 691 y 692 del Código Civil).

Por último, el artículo 693 del Código Civil añade que, si el notario considera acreditada la autenticidad del testamento, autorizará el acta de protocolización, en la que harán constar las actuaciones realizadas y, en su caso, las observaciones manifestadas.

Si el testamento no fuera adverado, por no acreditarse suficientemente la identidad del otorgante, se procederá al archivo del expediente sin protocolizar aquel.

Autorizada o no la protocolización del testamento ológrafo, los interesados no conformes podrán ejercer sus derechos en el juicio que corresponda.

CUESTIÓN

Raúl redactó en su residencia de Madrid un testamento ológrafo (de su puño y letra). Señala la respuesta correcta:

- El testamento debe otorgarse ante notario en todo caso.
- El testamento de Raúl será válido si reúne todas las formalidades que establece la ley y el mismo se protocolice en los cinco años siguientes al fallecimiento de Raúl.
- El testamento de Raúl no es válido, ya que el mismo no consta en escritura pública.
- El testamento de Raúl solo será válido en el caso de que esté firmado por un testigo.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Testamento abierto**

El testamento abierto se regula en los artículos 694 a 705 del CC.

El testamento abierto es **aquel testamento en el que el testador manifiesta siempre su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone.**

Dentro del testamento abierto es importante distinguir dos modalidades:

◆ **El testamento abierto ante notario**

El testamento abierto ante notario se caracteriza por la intervención de la figura del notario, testigos y, en ocasiones, otras personas, dependiendo de las circunstancias personales que rodean al testador. Esta modalidad de testamento abierto se encuentra regulada en los arts. 694 a 699 del Código Civil.

El artículo 694 del Código Civil dispone que el testamento abierto **deberá ser otorgado ante notario hábil para actuar en el lugar del otorgamiento.**

En cuanto a las formalidades de esta modalidad del testamento abierto, el artículo 695 del Código Civil contiene las mismas:

- El **testador expresará** oralmente o por escrito o mediante cualquier medio técnico, material o humano su **última voluntad** al notario.
- El **notario redactará el testamento con arreglo a la voluntad del testador y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento.**
- El notario advertirá al testador del derecho que ostenta de leerlo por sí mismo.
- Una vez advertido, lo **leerá el notario en voz alta para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad.**
- Si estuviere conforme, **será firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir.**
- **Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los testigos.**
- Cuando el testador tenga dificultad o imposibilidad para leer el testamento o para oír la lectura de su contenido, el notario se asegurará, utilizando los medios técnicos, materiales o humanos adecuados, de que el testador ha entendido la información y explicaciones necesarias y de que conoce que el testamento recoge fielmente su voluntad.

El notario dará fe de conocer al testador o de haberlo identificado debidamente y, en su defecto, efectuará la declaración prevista en el artículo 686 del Código Civil. También hará constar que, a su juicio, se halla el testador con la capacidad legal necesaria para otorgar testamento, tal y como dispone el artículo 696 del Código Civil.

Al acto de otorgamiento **deberán concurrir dos testigos idóneos**, según el artículo 697 del Código Civil:

- Cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento.
- Cuando el testador o el notario lo soliciten.

El artículo 698 del Código Civil señala que al otorgamiento también deberán concurrir:

- Los testigos de conocimiento, si los hubiera, quienes podrán intervenir además como testigos instrumentales (recuérdese que los testigos de conocimiento son aquellos que intervienen en la autorización de un documento con la finalidad de identificar a los otorgantes que el notario no conoce de manera directa, mientras que los instrumentales son aquellos que firman junto al notario el hecho y el contenido del otorgamiento).
- Los facultativos que hubieran reconocido al testador incapacitado.
- El intérprete que hubiera traducido la voluntad del testador a la lengua oficial empleada por el notario.

Todas las formalidades indicadas se practicarán en un solo acto que comenzará con la lectura del testamento, sin que sea lícita ninguna interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero (art. 699 del Código Civil).

♦ El testamento abierto sin intervención de notario

El testamento abierto sin intervención de notario es aquel que, por las especiales dificultades que acarrea la presencia del mismo (casos de peligro inminente de muerte y de epidemia) se otorgará ante testigos.

La regulación del testamento abierto sin intervención de notario se encuentra en los arts. 700 a 704 del Código Civil.

El art. 700 del Código Civil establece que el testador que se halle en peligro de muerte puede otorgar el testamento ante cinco testigos idóneos. En el caso de epidemia el testamento puede ser otorgado ante tres testigos mayores de dieciséis años (art. 701 del Código Civil).

A TENER EN CUENTA. La regulación del otorgamiento de testamento en peligro de muerte ha sido objeto de examen en la convocatoria de 2023.

El artículo 703 del Código Civil indica que los testamentos, en caso de peligro de muerte o de epidemia, **serán ineficaces si pasasen dos meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte, o haya cesado la epidemia.**

Cuando el testador falleciere en dicho plazo, también quedará ineficaz el testamento si dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al notario competente para que lo eleve a escritura pública, ya se haya otorgado por escrito o verbalmente.

Por último, los testamentos otorgados sin autorización del notario serán ineficaces si no se elevan a escritura pública y se protocolizan en la forma prevenida en la legislación notarial (art. 704 del Código Civil).

➤ Testamento cerrado

El testamento cerrado ha de ser escrito y si el testador lo escribiese de su puño y letra pondrá su firma al final. Si estuviese escrito por cualquier medio técnico o por otra persona a ruego del testador, este pondrá su firma en todas sus hojas y al pie del testamento. Si el testamento se ha redactado en soporte electrónico, deberá firmarse con una firma electrónica reconocida (art. 706 del CC).

En todo caso, antes de la firma se salvarán las palabras enmendadas, tachadas o escritas entre renglones.

El artículo 707 del Código Civil contiene las **solemnidades que se observarán en el otorgamiento del testamento cerrado**:

- El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta, cerrada y sellada de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta.
- El testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrará y sellará en el acto, ante el notario que haya de autorizarlo.
- En presencia del notario, manifestará el testador por sí, o por medio del interprete previsto en el artículo 684 del Código Civil, que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se halla escrito y firmado por él o si está escrito de mano ajena o por cualquier medio mecánico, y firmado al final y en todas sus hojas por él o por otra persona a su ruego.
- Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario la correspondiente acta de su otorgamiento, expresando el número y la marca de los sellos con que está cerrado, y dando fe del conocimiento del testador o de haberse identificado su persona en la forma prevenida en los artículos 685 y 686 del Código Civil, y de hallarse, a su juicio, el testador con la capacidad legal necesaria para otorgar testamento.
- Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo y, en su caso, las personas que deban concurrir, y la autorizará el notario con su signo y firma. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los dos testigos idóneos que en este caso deben concurrir (se expresará esta circunstancia de darse la misma).
- Deberán concurrir al acto de otorgamiento dos testigos idóneos si así lo solicitase el testador o notario.

El artículo 708 del Código Civil establece la **prohibición de llevar a cabo testamento cerrado para aquellas personas que no sepan o no puedan leer**. Las personas con discapacidad visual podrán otorgarlo, utilizando medios mecánicos o tecnológicos que les permitan escribirlo y leerlo, siempre que se observen los restantes requisitos de validez establecidos en este código.

Por contra, sí podrán otorgar testamento cerrado aquellas personas que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, siempre que se cumplan una serie de requisitos, tal y como indica el artículo 709 del Código Civil, observándose lo siguiente:

- **El testamento ha de estar firmado por el testador.** En cuanto a los demás requisitos, se estará a lo dispuesto en el artículo 706 del CC.
- Al hacer su presentación, el testador escribirá en la parte superior de la cubierta, a presencia del notario, que dentro de ella se contiene su testamento, expresando cómo está escrito y que está firmado por él.
- A continuación de lo escrito por el testador, se extenderá el acta de otorgamiento, dando fe el notario de haberse cumplido lo prevenido en el número anterior y lo demás que se dispone en el artículo 707 del CC en lo que sea aplicable al caso.

Las personas con discapacidad visual, al hacer la presentación del testamento, deberán haber expresado en la cubierta, por medios mecánicos o tecnológicos que les per-

mitan leer lo escrito, que dentro de ella se contiene su testamento, expresando el medio empleado y que el testamento está firmado por ellas.

Una vez el testamento cerrado sea autorizado, el notario lo entregará al testador, después de poner en el protocolo corriente copia autorizada del acta de otorgamiento (art. 710 del Código Civil).

El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, o encomendar su guarda a persona de su confianza, o depositarlo en poder del notario autorizante para que lo guarde en su archivo, según el artículo 711 del Código Civil.

El artículo 712 del Código Civil establece que la persona que tenga en su poder un testamento cerrado deberá presentarlo ante notario competente en los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador.

El notario autorizante de un testamento cerrado, constituido en depositario del mismo por el testador, deberá comunicar, en los diez días siguientes a que tenga conocimiento de su fallecimiento, la existencia del testamento al cónyuge sobreviviente, a los descendientes y a los ascendientes del testador y, en defecto de estos, a los parientes colaterales hasta el cuarto grado.

En los dos supuestos anteriores, de no conocer la identidad o domicilio de estas personas, o si se ignorase su existencia, el notario deberá dar la publicidad que determine la legislación notarial.

El incumplimiento de este deber, así como el de la presentación del testamento por quien lo tenga en su poder o por el notario, le hará responsable de los daños y perjuicios causados.

El artículo 713 del Código Civil estipula que, el que con dolo deje de presentar el testamento cerrado que obre en su poder dentro del plazo fijado en el artículo 712 del Código Civil, así como el que lo sustrajere dolosamente del domicilio del testador o de la persona que lo tenga en guarda o depósito y el que lo oculte, rompa o inutilice de otro modo, además de la responsabilidad que en él se determina, perderá todo derecho a la herencia, si lo tuviere como heredero abintestato o como heredero o legatario por testamento, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que proceda.

Para la apertura y protocolización del testamento cerrado, se observará lo previsto en la legislación notarial (art. 714 del Código Civil).

Por último, el artículo 715 del Código Civil señala que **el testamento cerrado en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades establecidas en esta sección es nulo**; y el notario que lo autorice será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan, si se probare que la falta procedió de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables. Será válido, sin embargo, como testamento ológrafo, si todo él estuviere escrito y firmado por el testador y tuviere las demás condiciones propias de este testamento.

➤ **Testamento militar**

El artículo 716 del Código Civil se encarga de enumerar aquellas personas que, en tiempo de guerra, podrán otorgar testamento militar ante un oficial que tenga, por lo menos, la categoría de capitán. Además, el citado artículo remarca la obligación de que el testamento militar sea otorgado siempre en presencia de testigos.

Estas personas son:

- Militares en campaña.
- Voluntarios.
- Rehenes.
- Prisioneros.
- Demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este.

Su regulación abarca desde el artículo 716 al artículo 721 del CC.

➤ **Testamento marítimo**

El artículo 722 del Código Civil dispone que los testamentos abiertos o cerrados de los que durante un viaje marítimo vayan a bordo se otorgarán de la forma siguiente:

- a) Si el buque es de guerra, ante el contador o el que ejerza sus funciones, en presencia de dos testigos idóneos que vean y entiendan al testador. El comandante del buque, o el que haga sus veces, pondrá además su visto bueno.
- b) En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán, o el que haga sus veces, con asistencia de dos testigos idóneos.

En uno y otro caso los testigos se elegirán entre los pasajeros, si los hubiere; pero uno de ellos, por lo menos, ha de poder firmar, el cual lo hará por sí y por el testador, si este no sabe o no puede hacerlo.

Su regulación abarca desde el artículo 722 al 731 del CC.

➤ **Testamento hecho en país extranjero**

El artículo 732 del Código Civil dispone que los españoles podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las formas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca.

Podrán asimismo hacer testamento ológrafo, con arreglo al artículo 688 del Código Civil, aun en los países cuyas leyes no admitan dicho testamento.

Su regulación abarca desde el artículo 732 al artículo 736 del CC.

La legítima

La legítima es definida por el Código Civil como la **porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley** a determinados herederos, llamados **herederos forzosos** (art. 806 del CC). Por su parte, encontramos la regulación de la **protección de la que gozan los legitimarios** en los artículos 813 a 819 del Código Civil.

El artículo 813 del Código Civil señala que el testador no podrá privar a los herederos de su legítima sino en los casos expresamente determinados por la ley. Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo de viudo/a y lo establecido en los artículos 782 y 808 del Código Civil.

Son herederos forzosos de acuerdo con el artículo 807 del Código Civil:

- Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes.
- A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes.
- El viudo o viuda en la forma y medida que establece este código.

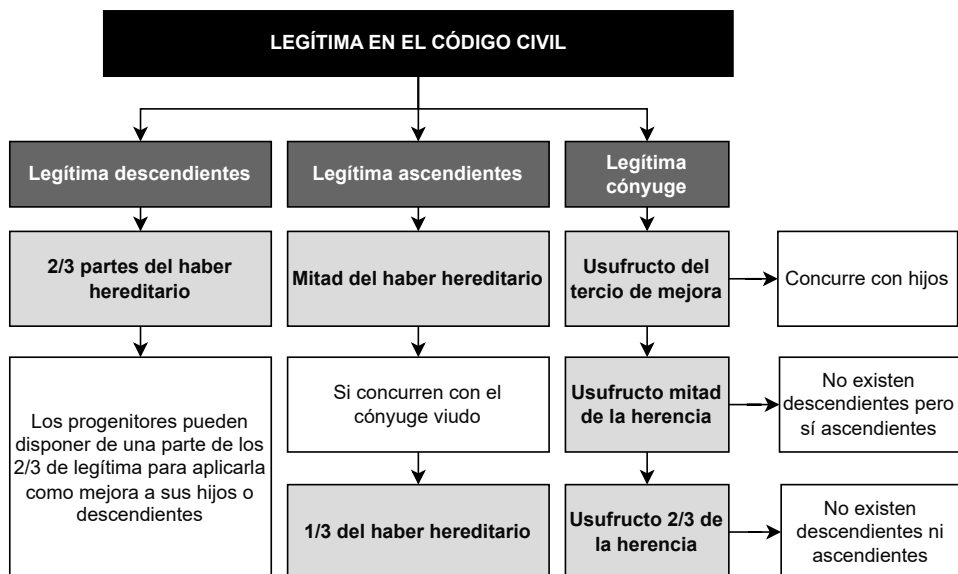
Hablamos de **preterición** cuando, en la sucesión testada, nos encontramos con **el testador ha omitido a un legitimario**. La preterición puede ser intencionada o no intencionada. La preterición se regula en el artículo 814 del Código Civil.

Nuestro ordenamiento jurídico no permite la renuncia o transacción sobre la legítima futura. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 816 del Código Civil.

Ahora bien, en aquellos supuestos en los que la renuncia se produzca **abierta la sucesión, esta será válida**.

En lo que respecta al **alcance de la legítima**, es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **Legítima de descendientes:** el artículo 808 del Código Civil entiende que constituye la **legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes (2/3) del haber hereditario de los progenitores**. Sin embargo, los progenitores podrán disponer de una parte de las dos que forman la legítima para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes. La tercera parte restante será de libre disposición. Cuando alguno o varios de los legitimarios se encontraran en una situación de discapacidad, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad. En tal caso, salvo disposición contraria del testador, lo así recibido por el hijo beneficiado quedará gravado con sustitución fideicomisaria de residuo a favor de los que hubieren visto afectada su legítima estricta y no podrá aquel disponer de tales bienes ni a título gratuito ni por acto *mortis causa*.
- Cuando el testador hubiere hecho uso de la facultad que le concede el párrafo anterior, corresponderá al hijo que impugne el gravamen de su legítima estricta acreditar que no concurre causa que la justifique.
- **Legítima de los ascendientes:** se encuentra regulada en los artículos 809 a 812 del Código Civil y se traduce en la **mitad del haber hereditaria**, salvo **el caso que concurrieran con el cónyuge viudo del descendiente causante**, en cuyo supuesto será de una tercera parte de la herencia.
- **Legítima del cónyuge:** encuentra su regulación en los artículos 834 a 840 del Código Civil y se traduce en:
 - El **usufructo del tercio destinado a mejora**, si concurre a la herencia con hijos o descendientes.
 - El **usufructo de la mitad de la herencia** cuando no concurren descendientes, pero sí ascendientes.
 - El **usufructo de dos tercios de la herencia** cuando no existen descendientes ni ascendientes.

**CUESTIONES**

1. Lucas es vecino de Valladolid, viudo y con dos hijos. Tiene intención de hacer testamento, pero le gustaría saber cuál es la parte de sus bienes de la que no puede disponer como consecuencia de la legítima que les corresponde a sus descendientes. Señala la respuesta correcta:

- a) Lucas puede disponer de la mitad del haber hereditario a la hora de hacer el testamento.
- b) La legítima de sus descendientes la constituye una tercera parte del haber hereditario.
- c) Constituye la legítima las dos terceras partes del haber hereditario de Lucas, si bien podrá disponer de una parte de las dos que forman la legítima para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.
- d) Constituye la legítima la cuarta parte del valor del haber hereditario, que podrá repartir a partes iguales o a partes desiguales entre sus dos hijos.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. Samuel, de vecindad civil común, concurre a la herencia de su cónyuge con los padres de esta sin existir descendientes. ¿Qué legítima le pertenece a Samuel?

- a) Tendrá derecho al usufructo de la mitad del haber hereditario.
- b) Tendrá derecho al usufructo de dos tercios del haber hereditario.
- c) Tendrá derecho al usufructo de un tercio del haber hereditario.
- d) Al concurrir con los ascendientes a Samuel, no le corresponde legítima.

RESPUESTA CORRECTA: A

Asimismo, los progenitores podrán disponer de una de las partes de las dos que forman la legítima para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes. Igual que la legítima, el tercio de mejora está destinado a los herederos forzosos.

La **asignación de la mejora será siempre por voluntad del testador**, por lo que el mismo podrá asignar todos los bienes destinados al tercio de mejora a uno o varios hijos, asignar solo una parte de los bienes integrantes del tercio de mejora a favor de uno o algunos de los hijos o, por el contrario, no disponer del tercio destinado a mejora. En estos dos últimos casos, los bienes destinados al tercio de mejora se integrarán en el tercio de legítima estricta y deberán ser repartidos por partes iguales entre sus hijos o descendientes.

Es decir, **el testador no está obligado a repartir sus bienes equitativamente entre sus hijos o descendientes siempre que respete el tercio de legítima estricta**.

A TENER EN CUENTA. Hay que distinguir entre mejora y el tercio de mejora. El tercio de mejora es la proporción de bienes que los padres pueden establecer exclusivamente a favor de sus hijos o descendientes y la mejora es la parte de bienes que los padres pueden realizar a uno o varios hijos o descendientes, pero a cargo del tercio que disponen para mejora.

TERRITORIO	LEGISLACIÓN	LEGITIMARIOS	CUOTA LEGÍTIMA	CUOTA USUFRUCTO
GALICIA	Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia (artículos 238 a 257).	Hijos y descendientes de hijos premuertos, justamente desheredados o indignos y cónyuge viudo no separado legalmente o de hecho.	Cuarta parte del valor del haber hereditario líquido para los descendientes.	Concurre con descendientes: cuarta parte del valor del haber hereditario líquido No concurre con descendientes: mitad del capital.
PAÍS VASCO	Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco (artículos 47 a 60).	Los hijos o descendientes en cualquier grado y cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho (se puede elegir entre ellos pudiendo apartar a los demás).	Tercio del caudal hereditario para los descendientes.	Mitad de todos los bienes del causante si concurre con descendientes. En defecto de descendientes, dos tercios.

TERRITORIO	LEGISLACIÓN	LEGITIMARIOS	CUOTA LEGÍTIMA	CUOTA USUFRUCTO
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	Ley 1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra (artículos 267 a 271).	Los hijos y, en defecto de ellos, a sus respectivos descendientes de grado más próximo.	Atribución de « <i>cinco sueldos “febles” o “carlines” por bienes muebles y una robada de tierra en los montes comunes por inmuebles</i> ». Disposición simbólica no es obligatorio dejar ninguna cuota a los legitimarios.	No hay.
ARAGÓN	Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código de Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas (artículos 486 a 502).	Descendientes de cualquier grado.	La mitad del caudal hereditario (puede distribuirse igual o desigualmente, entre todos o varios de los descendientes).	No hay. *Debe tenerse en cuenta que el viudo tiene derecho al usufructo viudal (arts. 283 y ss), pero no se considera legítima.
CATALUÑA	Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones (artículos 451-1 a 451-27).	Todos los hijos del causante por partes iguales y si no hay descendientes que le hayan sobrevivido, serán legitimarios los progenitores .	La cuarta parte de la cantidad base del haber hereditario.	No hay.

TERRITORIO	LEGISLACIÓN	LEGITIMARIOS	CUOTA LEGÍTIMA	CUOTA USUFRUCTO
MALLORCA Y MENORCA	Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la compilación del derecho civil de las Islas Baleares (artículos 41 a 51).	Hijos y descendientes, los progenitores y el cónyuge viudo.	Hijos y descendientes: tercera parte del haber hereditario si son 4 o menos, y la mitad si exceden de 4 Progenitores: la cuarta parte del haber hereditario. Concurriendo ambos progenitores, se dividirá entre ellos por mitad y si alguno hubiera premuerto, corresponderá íntegra al sobreviviente.	En concurrencia con descendientes: la mitad del haber hereditario. En concurrencia con progenitores: dos tercios y en los demás supuestos, usufructo universal.
IBIZA Y FORMENTERA	Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la compilación del derecho civil de las Islas Baleares (artículo 79 a 83) Y la legítima de los progenitores se regirá por lo dispuesto en el Código Civil (artículo 809 y 810, párrafo primero).	Los hijos y descendientes y los progenitores.	Descendientes: la tercera parte del haber hereditario si fueren cuatro o menos de cuatro, y por la mitad de la herencia si fueren más. Progenitores: la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes salvo el caso en que concurrieren con el cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo supuesto será de una tercera parte de la herencia.	No hay.

1640

La sucesión intestada

La sucesión intestada se encuentra regulada en los artículos 912 a 929 del Código Civil.

Puede definirse la sucesión intestada como aquella **sucesión hereditaria que se define por la ley a falta de testamento o, existiendo este, por su ineficacia o imposibilidad de ejecución, o por la falta de previsión de los herederos forzosos.**

La sucesión legítima tiene lugar (art. 912 del Código Civil):

- Cuando uno **muere sin testamento**, o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez.
- Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.
- Cuando falta la condición puesta a la institución del heredero, o este muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer.
- Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.

A falta de herederos testamentarios, la ley define a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado, según el artículo 913 del Código Civil.

El artículo 914 del Código Civil establece que, lo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por testamento es aplicable igualmente a la sucesión intestada.

5.4. Partición de la herencia

1650

Procedimientos para la partición de la herencia

Respecto a los tipos de partición hereditaria, se hace necesario destacar las distintas maneras por las que puede llevarse a cabo. En este sentido, se considera que la partición puede ser:

➤ Partición judicial de la herencia

La partición judicial de la herencia tendrá lugar cuando el **testador no la ha realizado ni tampoco ha nombrado a contador-partidor, así como cuando no exista acuerdo entre los coherederos para la distribución del caudal relicto.**

Así se infiere del artículo 1059 del Código Civil, y también de lo dispuesto en el apartado primero del **artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Civil**, a través del que se indica lo siguiente:

«1. **Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia**, siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el letrado de la Administración de Justicia o el Notario.

2. A la solicitud deberá acompañarse el certificado de defunción de la persona de cuya sucesión se trate y el documento que acredite la condición de heredero o legatario del solicitante.

3. Los acreedores no podrán instar la división, sin perjuicio de las acciones que les correspondan contra la herencia, la comunidad hereditaria o los coherederos, que se ejercitarán en el juicio declarativo que corresponda, sin suspender ni entorpecer las actuaciones de división de la herencia.

4. No obstante, los acreedores reconocidos como tales en el testamento o por los coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos. Esta petición podrá deducirse en cualquier momento, antes de que se produzca la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero.

5. Los acreedores de uno o más de los coherederos podrán intervenir a su costa en la partición para evitar que esta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos».

El **procedimiento de división judicial de herencia** es un proceso especial que se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 782 y siguientes:

COMPETENCIA	Lugar en que el causante tuvo su último domicilio y si este fuese extranjero, podrá elegir el demandante entre el tribunal del lugar del último domicilio en España o donde tuviese la mayor parte de sus bienes (art. 52.1.4.º de la LEC).
LEGITIMACIÓN Y CAPACIDAD	Cualquier heredero o legatario de parte alícuota, siempre que la partición no deba efectuarla un comisionario o contador-partidor designado por el testador.
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	La acción de división judicial de la herencia es imprescriptible .
REQUISITOS FORMALES Y POSTULACIÓN	Preceptiva intervención abogado y procurador. A la demanda deberá acompañarse el certificado de defunción y el documento que acredite la condición de heredero . Es necesario para presentar la demanda acudir previamente a un MASC , por lo que es necesario acreditar el haber intentado, con carácter previo a la misma, solucionar el conflicto a través de MASC.

CUESTIONES

1. Laura quiere interponer demanda para que se lleve a cabo la partición de la herencia de su madre, que falleció el 20 de enero de 2011. Laura no sabe si ha prescrito la acción de división. Señala la respuesta correcta:

- a) Laura puede interponer la demanda para que se lleve a cabo la partición de la herencia de su madre, ya que la acción de división judicial de herencia es imprescriptible.
- b) Laura no puede interponer demanda de división judicial de la herencia, ya que la acción prescribe a los cinco años desde el fallecimiento del causante.
- c) Laura podrá interponer demanda de división judicial de la herencia de su madre, pero antes deberá acreditar ante el Ministerio Fiscal su condición de heredera al haber transcurrido más de 5 años desde el fallecimiento de la causante.
- d) Laura no puede interponer demanda de división judicial de la herencia, ya que la acción prescribe a los tres años desde el fallecimiento del causante.

RESPUESTA CORRECTA: A

2. Julio es acreedor de Cayetano, que falleció el 10 de agosto de 2019. A día de hoy, todavía no se ha llevado a cabo la partición de la herencia de Cayetano. Julio, como acreedor de Cayetano, ¿puede interponer demanda de división judicial de la herencia?

- a) Sí, los acreedores podrán reclamar judicialmente la división de la herencia en todo caso.
- b) Julio podrá reclamar judicialmente la división de la herencia únicamente si es reconocido como acreedor en el testamento o por los coherederos.
- c) Julio podrá reclamar judicialmente la división de la herencia únicamente si el importe del crédito es superior a 6.000 euros.
- d) Julio no podrá instar la división judicial de la herencia. No obstante, si está reconocido como acreedor en el testamento o por los coherederos y si tiene su derecho documentado en un título ejecutivo podrá oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se pague o afiance el importe de sus créditos.

RESPUESTA CORRECTA: D

➤ **Partición extrajudicial de la herencia hecha por el propio testador**

De acuerdo con el **artículo 1056 del Código Civil**:

«Cuando el testador hiciere, **por acto entre vivos o por última voluntad**, la partición de sus bienes, se pasará por ella, **en cuanto no perjudique a la legítima de los herederos forzosos**.

El testador que en atención a la conservación de la empresa o en interés de su familia quiera preservar indivisa una explotación económica o bien mantener el control de una sociedad de capital o grupo de estas podrá usar de la facultad concedida en este artículo, disponiendo que se pague en metálico su legítima a los demás interesados. A tal efecto, no será necesario que exista metálico suficiente en la herencia para el pago, siendo posible realizar el abono con efectivo extrahereditario y establecer por el testador o por el contador-partidor por él designado aplazamiento, siempre que este no supere cinco años a contar desde el fallecimiento del testador; podrá ser también de aplicación cualquier otro medio de extinción de las obligaciones. Si no se hubiere establecido la forma de pago, cualquier legitimario podrá exigir su legítima en bienes de la herencia. No será de aplicación a la partición así realizada lo dispuesto en el artículo 843 y en el párrafo primero del artículo 844».

Asimismo, **la partición hecha por el difunto no puede ser impugnada por causa de lesión**, sino en el caso de que perjudique la legítima de los herederos forzosos o de que aparezca, o racionalmente se presuma, que fue otra la voluntad del testador.

➤ **Partición de la herencia extrajudicial por comisionario o contador-partidor**

Este tipo de partición extrajudicial se establece en el artículo 1057 del Código Civil al precisar que «El testador podrá encomendar por acto “inter vivos” o “mortis causa” **para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de los coherederos**».

Este tipo de partición tendrá lugar cuando el testador encomienda la partición, para después de su fallecimiento, a una persona que habrá de ser distinta de los coherederos.

➤ **Partición extrajudicial de la herencia por los coherederos**

También denominada «partición convencional», se regula en el artículo 1058 del Código Civil, el cual establece que «Cuando el testador no hubiese hecho la partición, ni encomenda-

do a otro esta facultad, si los herederos fueren mayores y tuvieran la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente».

La partición de la herencia por los herederos podrá hacerse en documento privado o público ante notario.

Los requisitos para que los coherederos puedan proceder esta partición son dos:

1. **Mayoría de edad.**
2. **Capacidad para la libre administración de sus bienes.**

La partición hecha por los coherederos **requiere unanimidad en su acuerdo** y, en caso de que tal acuerdo no exista, quedaría el recurso a la partición judicial.

➤ **Partición extrajudicial de la herencia por el contador partidor dativo**

El contador partidor dativo es aquella persona **nombrada mediante procedimiento judicial** (art. 92 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria) o notarial (art. 66 de la Ley del Notariado), **a petición de los herederos y legatarios que representen al menos el cincuenta por ciento del haber hereditario**, en los siguientes supuestos:

1. Cuando no haya testamento (declaración de herederos abintestato).
2. Cuando no exista contador partidor testamentario, bien por no haber sido nombrado por el testador, o bien por quedar vacante el cargo.

Artículo 1057 del Código Civil

«El testador podrá encomendar por acto «inter vivos» o «mortis causa» para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de los coherederos.

No habiendo testamento, contador-partidor en él designado o vacante el cargo, el letrado de la Administración de Justicia o el Notario, a petición de herederos y legatarios que representen, al menos, el 50 por 100 del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador-partidor dativo, según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designación de peritos. La partición así realizada requerirá aprobación del letrado de la Administración de Justicia o del Notario, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios.

Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los coherederos haya alguno sujeto a patria potestad o tutela; pero el contador-partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de los representantes legales de dichas personas.

Si el coheredero tuviera dispuestas medidas de apoyo, se estará a lo establecido en ellas».

Operaciones particionales en la división de la herencia

1660

En el proceso de partición de la herencia pueden distinguirse las siguientes fases:

➤ **Inventario**

La primera fase para proceder a la partición de la herencia es la formación de inventario, que es una relación de bienes, derechos y obligaciones que componen el caudal relicto para su posterior valoración y liquidación.

Para realizar el inventario, es preciso hacer una distinción entre el activo y el pasivo de la masa hereditaria.

➤ **Avalúo**

Es la asignación de un valor económico a los bienes de la herencia que realizará quien haga la partición, o bien se encargará, según los casos, a entidades especializadas o peritos. Para ello, con carácter general se acude al valor de mercado de los bienes.

➤ **Liquidación**

Es la operación mediante la cual se deduce del activo el pasivo para obtener el activo neto, es decir, el haber líquido partible. Por lo tanto, al valor de los bienes incluidos en el inventario, habrá de restarle las deudas y demás pasivo que supondrán una disminución del patrimonio hereditario.

➤ **Formación de lotes**

Una vez realizada la liquidación se procederá a la formación de lotes según las cuotas legales o testamentarias para la adjudicación o entrega a los coherederos de los bienes que les correspondan. En esa formación de lotes habrá de respetarse en la medida de lo posible la igualdad, como preceptúa el artículo 1061 del Código Civil.

«En la partición de la herencia se ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad o especie».

➤ **Adjudicación**

Además de la entrega de los bienes que les correspondan debe entregarse a los coherederos cierta documentación señalada en los artículos 1065 y 1066 del CC:

- Artículo 1065: se entregarán los títulos de adquisición o pertenencia.
- Artículo 1066: cuando el mismo título comprenda varias fincas adjudicadas a diversos coherederos o una sola se haya dividido entre varios, el título queda en poder del mayor interesado y se entregarán copias a los demás. Si el interés fuera igual, se estará a lo que acuerden y, a falta de acuerdo, se decidirá por sorteo.

➤ **Colación**

La colación se realiza en los casos en los que existan herederos forzosos y alguno o varios de ellos hayan recibido en vida del causante bienes mediante atribuciones gratuitas. Así se regula en el artículo 1035 del Código Civil:

«El heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión, **deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de este, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición**».

Los requisitos para la existencia y exigencia de la colación son los siguientes:

- **Concurrencia de herederos forzosos en una misma sucesión:** la obligación de colacionar solo puede corresponder al heredero forzoso que concurra con otros que también lo sean, pero en ningún caso a los donatarios extraños.
- **Que uno o varios de ellos hayan recibido del causante de la herencia, en vida de este, determinados bienes «liberalidades *inter vivos*»:** este requisito es ineludible para que surja la obligación de colacionar, de acuerdo con el artículo 1035 del CC.

- **Que la recepción de bienes lo haya sido, por vía de dote, donación u otro título lucrativo, es decir, actos a título gratuito:** la colación no alcanza a los bienes adquiridos por del causante por título oneroso en contrato válido y eficaz.
- **Que los bienes mismos o su valor se traigan a la masa hereditaria para ser computados en la regulación de la legítima y en la cuenta de la partición:** de acuerdo con el artículo 1045 del CC, no han de traerse a colación las mismas cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios.

El funcionamiento de la colación, como una operación no tanto de la partición, sino como previa a la misma, es por adición contable a la masa hereditaria del valor de los bienes donados, cuyo valor será el del momento de la partición de acuerdo con el artículo 1045 del CC.

Por lo tanto, **su finalidad es guardar la igualdad o proporcionalidad de las percepciones de los legitimarios.**

La colación no tendrá lugar entre los herederos forzosos si el donante así lo hubiera dispuesto expresamente o si el donatario repudiare la herencia, salvo en los casos en los que la donación deba reducirse por inoficiosa, de acuerdo con el artículo 1036 del CC.

Se distinguen dos tipos de gastos hechos por los padres en vida de los hijos que no son colacionables:

1. **Gastos no colacionables:** gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades (aunque sean extraordinarias), aprendizaje, equipo ordinario, regalos de costumbre, gastos para cubrir las necesidades especiales de hijos o descendientes con discapacidad.
2. **Gastos no colacionables salvo disposición o perjuicio de la legítima:** gastos hechos para dar a su hijo una carrera profesional o artística; pero cuando proceda colacionarlos, se rebajará de ellos lo que el hijo habría gastado viviendo en la casa y compañía de sus padres.

Con respecto a **los frutos e intereses de los bienes sujetos a colación**, no se deben a la masa hereditaria sino desde el día en que se abra la sucesión. Para regularlos se atenderá a las rentas e intereses de los bienes hereditarios de la misma especie que los colacionados (artículo 1049 del CC).

Por otra parte, **la colación no debe confundirse con la computación.** La computación ha de llevarse a cabo aun cuando exista un único legitimario, pues su legítima puede verse perjudicada por las donaciones efectuadas por el causante a terceras personas, mientras que la colación del mencionado artículo 1035 del CC únicamente tiene lugar cuando concurren a la herencia herederos forzosos.

CUESTIÓN

¿Cuáles de los siguientes bienes deberán colacionarse?

- a) Los bienes que se hayan recibido por parte del causante de la herencia por vía de dote, donación u otro título lucrativo.
- b) Bienes donados en vida para el tratamiento médico de un heredero forzoso.
- c) Todos los bienes donados en vida a los legitimarios, aunque el/la causante hubiera hecho con expresa mención a su carácter no colacionable.
- d) Todos los bienes que hayan recibido los herederos forzosos del/de la causante, excepto los recibidos a título gratuito.

RESPUESTA CORRECTA: A